

1501432-94.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... o local é conhecido pela prática de tráfico, usaram uma tática diferente, viu um rapaz servindo droga para um gol branco e ele foi detido por seu colega, foi jogando dinheiro pelo mato, conseguiram resgatar parte do valor e com ele havia droga. Ele confessou os fatos. Ouvido o PM GRAZIANO CIOLA DIAS, disse que o local é conhecido por tráfico e toda vez que a viatura vem eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501432-94.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2250789-38.2021.070922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ LUÍS COSTA CESARIO

Contr. nº 2021/001006

Aos 29 de setembro de 2022, às 16:20 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Sandra Regina Ferreira da Costa, foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu KAUÃ LUIS COSTA CESARIO.

Presente a Defensoria Pública na pessoa da Dra. Carolina Romani Brancalion.

Presentes as testemunhas comuns: PMs Graziano Ciola Dias e Carlos Alberto Morasco.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, através de exibição à câmera de documento original com foto, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PM Carlos Alberto e PM Graziano) e, em seguida, o interrogatório do réu foi captado, todos gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências. Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foram apresentadas alegações finais ORAIS gravadas por meio audiovisual.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). KAUÃ LUIS COSTA CESARIO foi denunciado no delito tipificado pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão de fatos ocorridos no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 19 horas e 22 minutos, na rua Ibitinga, altura do nº 70, bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 128 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 86g (cf. laudo de fls. 20), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Preso em flagrante, o acusado foi interrogado pela Autoridade Policial (fls. 6-7), confessou os fatos. Posteriormente, distribuído o feito a este Juízo foi convertida a prisão (fls. 47/48) e impetrado habeas corpus, revogada a prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares diversas (fls. 59-73). Em seguida, efetuada a notificação, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia (fls. 136-137). Durante a instrução, foram ouvidos os dois policiais militares e o acusado. Ouvido o PM CARLOS ALBERTO MORASCO, disse que estava em serviço, o local é conhecido pela prática de tráfico, usaram uma tática diferente, viu um rapaz servindo droga para um gol branco e ele foi detido por seu colega, foi jogando dinheiro pelo mato, conseguiram resgatar parte do valor e com ele havia droga. Ele confessou os fatos. Ouvido o PM GRAZIANO CIOLA DIAS, disse que o local é conhecido por tráfico e toda vez que a viatura vem eles conseguem fugir, naquele dia dividiram a equipe, ele estava entregando droga para um gol, ele tentou fugir, mas conseguiu detê-lo. No percurso ele deixou cair dinheiro que conseguiram resgatar e na parte íntima dele encontraram a droga. Interrogado judicialmente, o réu afirmou ser verdade que estava traficando, não conseguia emprego e foi a única opção que teve, está arrependido e ainda está desempregado. Não tem outra passagem, possui 19 anos. Ao final, o Ministério Público pugnou pela condenação. 2. DA ABSOLVIÇÃO. 2.1. Da insuficiência probatória. Ademais, o caso é de absolvição em razão da insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), eis que deficitários os elementos de prova. De fato, a condenação estaria embasada apenas nos relatos dos policiais militares, os quais apenas descreveram suas diligências. Nesse contexto, não se pode deixar de levar em consideração que os policiais estão intimamente ligados ao fato criminoso, sendo manifestamente tendencioso o seu depoimento, já que tendentes a ratificar a sua atuação pré-processual e, eventualmente, encobrir qualquer tipo de irregularidade nela presente. Com efeito, os relatos oferecidos pelos agentes de segurança pública, contrariamente ao que ocorre com os demais cidadãos, não são dotados da necessária imparcialidade, na medida em que eles tenderão, por certo, a corroborar as diligências (e a própria prisão) efetivadas na fase extraprocessual, sendo naturalmente inclinados, portanto, a atestar a lisura das suas ações realizadas na fase investigativa. Por isso, em razão do princípio da interest disqualification, tais agentes não deveriam ser admitidos a prestar declarações[1]. Apesar disso, firmou-se uma posição intermediária, ou seja, fixou-se o entendimento de que os depoimentos dos agentes de segurança pública lei, sem o amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem embasar uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir ao referido elemento de prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a própria descoberta da verdade dos fatos[2]. Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que os testemunhos dos Policiais responsáveis pela realização do flagrante não são isentos e, por isso, devem ser corroborados por outros elementos de prova. Isso porque “Os policiais militares investigadores do fato, como verdadeiros assistentes da parte autora, não têm, sozinhos, em face da própria condição de servirem como longa manus do Ministério Público, enquanto ditam as provas, a isenção suficiente para demarcarem, através de seus exclusivos

depoimentos, um justo e razoável juízo de reprovação penal”. Logo, “Admitir-se entendimento outro é o mesmo que fazer ouvidos moucos ao som do retumbante princípio da proporcionalidade, desequilibrando, a não mais bastar, as atuações dos atores processuais, em manifesto e desmesurado prejuízo à ampla defesa do acusado, tornando-o sempre a parte vulnerável da ação penal, com mínimas chances, para não se dizer nenhuma, de se ver livre da imputação”[3]. [1] A esse propósito: “[...] é a partir do momento em que o júri deixa de decidir com base em conhecimento próprios, para servir-se de provas, fornecidas principalmente por testemunhas, que se inicia a formação de um conjunto de regras de exclusão (exclusionary rules), cuja finalidade é a de controlar a qualidade das provas apresentadas aos jurados, evitando que esses leigos pudessem ser induzidos a erros de apreciação. Dentre tais regras, sobressaem a rule against hearsay, destinada a evitar que o júri tenha contado com um testemunho de segunda mão, e o princípio da interest disqualification, segundo o qual não são admissíveis testemunhas que possam ter interesse na solução da causa [...]” (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 37-38). [2] Na doutrina: “Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. [...]. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável que o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de outras pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si” (Processo penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 492-493). No mesmo sentido: “Logicamente, [os Policiais] jamais descreveriam nos registros policiais que agiram utilizando violência ou algum procedimento ilegal. Por terem participado da ação, sua versão precisaria ser recepcionada com reservas. [...]. Não há impedimentos aos testemunhos de policiais, mas por terem participado da prisão, seria importante que suas palavras fossem recebidas com certa reserva, já que seus relatos poderiam ter o objetivo de imprimir uma legalidade e legitimidade de sua própria atuação” (JESUS, Maria Gorete Marques de. A verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2018, p. 248). [3] TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr, p. 8 do voto do Relator. É imperioso, por isso, que a condenação não seja proferida apenas com embasamento nas declarações dos policiais. Aliás, no que se refere à Polícia Militar, o Procedimento Operacional Padrão estabelecido em 11/4/2006, determina aos policiais que reúnam dados e testemunhas da ocorrência. Não se pode, assim, admitir que a condenação seja proferida apenas com base em depoimentos policiais. Ora, “Se a polícia militar ou a polícia civil têm agido na repressão ao tráfico de drogas, a ação de colheita de provas não pode ser viciada pelo intento repressivo. Em outras palavras, a polícia judiciária na sua atividade de colheita de provas deve estar subordinada aos mesmos princípios de todos os participantes da relação processual, ou seja, deve estar vinculada à necessidade de busca da verdade, não podendo deixar a repressão de que está imbuída prejudicar a imparcialidade necessária. Por isso defendeu-se a impossibilidade de se trazer apenas testemunhas policiais para o flagrante, formando completamente o conteúdo probatório testemunhal do futuro processo, porque depois é praticamente impossível para a defesa encontrar outras pessoas envolvidas com a conduta que possam trazer aspectos positivos e favoráveis ao réu, sendo obrigação da polícia encontrar testemunhas o mais isentas possíveis no momento do fato, atitude que poderia vir a favor não só dá defesa, mas da credibilidade do processo como um todo”[1]. Portanto, as declarações dos agentes de segurança pública devem ser apreciadas com cautela e corroboradas por outros elementos de prova, sob pena de se desnaturar o próprio processo penal. De fato, em

tal situação, “O processo, que era para ser o momento de verificar a existência do fato, torna-se um momento de verificar a repetição do que foi escrito pela polícia, o que não é a mesma coisa”[2]. Isso posto, sendo deficitário o conjunto probatório, não superado o standard probatório da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) – conclusão sobre a responsabilidade além de qualquer dúvida razoável – a absolvição é medida que se impõe (CPP, art. 386, VII). 3. DAS TESES SUBSIDIÁRIAS. 3.1. Da dosimetria de pena. No entanto, caso se entenda pela condenação, é certo que, em relação à dosimetria de pena, na primeira fase, a pena-base deverá ser fixada no patamar mínimo legal. De fato, o dolo é inerente à figura típica e as consequências são normais para casos similares, assim como os motivos para a prática do crime, não justificando uma exasperação na primeira fase. Ademais, de acordo com as certidões acostadas a estes autos, acusado é absolutamente primário, não possuindo qualquer condenação definitiva. Sob outro prisma, no que se refere à quantidade de drogas, não há justificativa para o aumento da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Isso porque o aumento da pena-base com fundamento no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 exige que a quantidade de drogas seja expressiva, conforme jurisprudência do TJ-SP e do STJ[3], não sendo este o caso dos presentes autos. A pena-base, portanto, deve permanecer no patamar mínimo legal. Na segunda etapa, deve incidir, em primeiro lugar, a atenuante do art. 65, I, do CP, porquanto o acusado, à época dos fatos, era menor de 21 anos de idade. Ainda na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), tendo em vista que o recorrente admitiu os fatos aos policiais. Nesse sentido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) ainda que se trate de confissão informal[4]. Logo, impõe-se a o reconhecimento da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”, e Súmula 545 do STJ). Por fim, na terceira fase de dosimetria de pena, , deve ser aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu máximo patamar. Sob outro prisma, no que se refere à quantidade e natureza das drogas apreendidas em poder da apelante, frise-se que somente podem ser valoradas em uma das etapas da dosimetria[5]. Além disso, referidas circunstâncias não autorizam a automática conclusão de que a imputada tenha envolvimento com crime, não se podendo utilizar tal argumentação para denegar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas[6]. [1] VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019, p. 516, grifos nossos. [2] VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019, p. 519. [3] TJ-SP, 2ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0003146-82.2017.8.26.0542 Rel. Des. Francisco Orlando, julgado em 10/6/2019. AgRg no HC 465.898/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. [4] AgRg no AREsp 583.205/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018. [5] ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014. [6] : RHC 138715, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017. Por fim, relativamente ao patamar de redução, a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em critério inferior a 2/3 somente se justifica quando a quantidade de drogas seja exacerbada, a quantidade apreendida se trata de 32 gramas de crack, o que não é o caso dos autos[1]. Isso posto, na terceira etapa de dosimetria de pena, deve ser aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu máximo patamar. 3.2. Do regime inicial de cumprimento de pena. Possibilidade de fixação do regime inicial aberto. Como sabido, o regime inicial deve ser fixado em estrita observância do art. 33 do Código Penal e, caso se entenda pela fixação de regime mais gravoso, a motivação deve dar-se de modo concreto, conforme se infere das Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedado apelar à gravidade em abstrato do delito para a fixação do regime inicial de pena. Além disso, em casos de tráfico de drogas, não poderá o regime ser definido com embasamento apenas no disposto no art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, tendo em vista que sua inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal[2]. Com isso,

no caso em análise, caso seja reconhecido o tráfico “privilegiado”, mostrar-se-á cabível o regime inicial aberto. Ora, o imputado é primário, as circunstâncias judiciais lhe são inteiramente favoráveis e a quantidade de pena não será superior a 4 anos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal é pacífico sobre a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para hipóteses similares, isto é, situações em que seja reconhecido o “tráfico privilegiado”[3]. Isso posto, deverá ser fixado o regime inicial aberto. 3.3. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Na hipótese de acolhimento da argumentação relativa à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que não seja aplicado o redutor em seu patamar mínimo, mostrar-se-á cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o acusado, visto que presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. Sobre esse ponto, ainda que a Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º, vede a conversão das penas privativas de liberdade em restritiva de direitos, é certo que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de parte desse dispositivo e o Senado Feral, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução desse trecho, dotando a decisão do STF de efeitos erga omnes e, dessa forma, afastando o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos[4]. Portanto, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. PEDIDOS. Perante o exposto, pugna-se: a) pela absolvição (CPP, art. 386, II, V ou VII); b) subsidiariamente: b.1) no que se refere à dosimetria de pena, (i) seja mantida a pena-base no patamar mínimo legal, (ii) sejam aplicadas as atenuantes previstas pelo art. 65, I, e III, “d”, do CP, e (iii) seja aplicada, no seu máximo patamar, a minorante do art. 33, § 4º, da LD; b.2) seja fixado o regime inicial aberto; b.3) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b.4) seja reconhecida a detração e o direito de recorrer em liberdade. c) por fim, seja o réu reconhecido como beneficiário do direito à gratuidade de justiça, suspendendo-se a exigibilidade da condenação em custas (CPC, art. 98, § 3º, c. c/ art. 3º do CPP). [1] STF, HC 136651, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017; STF, RHC 132860, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016; STJ, Recurso Especial n. 1.815.172-SP, Rel. Min. Sebastião Rei Júnior, julgado em 1º/8/2019. [2] STF, HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012. [3] HC 126571, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015. No mesmo sentido, em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis” (HC 596.603/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). Por fim, não é diverso o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação n. 0000930-51.2017.8.26.0542, julgado em 12/3/2019. [4] STF, HC 97256, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RTJ VOL-00220-01 PP-00402 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 279-333. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir: Vistos,

KAUÃ LUÍS COSTA CESARIO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 19 horas e 22 minutos, na Rua Ibitinga, altura do nº 70, Bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 128 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 86g (cf. laudo de fls. 20), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares foram informados da prática de tráfico no local indicado e também dispunham de informações de que os traficantes que ali atuavam desciam o barranco e se escondiam na favela "Portelinha" quando percebiam a aproximação da Polícia.

Narra, ainda, que os PMS se posicionaram em lugares estratégicos para evitar a fuga e, de onde estavam, notaram quando KAUÃ entregou um objeto ao condutor de um veículo que por ali chegou, em conduta típica de tráfico. Assim, convictos da prática ilegal, os PMS foram ao encontro do réu, e este, como esperado, desceu correndo o barranco em direção à comunidade. No caminho, dispensou R\$ 48,00 que trazia consigo, quantia posteriormente recolhida. KAUÃ foi abordado pela equipe de PMS que havia se posicionado na parte inferior do barranco e submetido à busca pessoal. Resultou da providência o encontro de 128 porções de cocaína em poder do acusado.

Narra, por fim, que o réu admitiu informalmente aos PMS que cada porção seria vendida ao preço de R\$ 20,00.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fl. 132). Defesa preliminar apresentada às fls. 136/137. Após, a denúncia foi recebida (fl. 139) e o réu foi citado (fl. 150).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 08/13;
- 2) auto de exibição e apreensão de fl. 14/15 e fotografia de fl. 18/19;
- 3) laudo de constatação de fls. 20/23 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 117/119, com resultados positivos para cocaína em relação à substância apreendida. A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fl. 06/07), o réu admitiu que a droga era de sua propriedade e que estava vendendo entorpecentes para sustentar sua casa.

Interrogado em juízo (gravação), repetiu a confissão.

A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Carlos Alberto Morasco disse que tinham informação de que, na Rua Ibitinga, Bairro Tatuapé, lugar já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, indivíduos realizavam a mercancia ilícita, sendo que eles ficavam na Rua Ibitinga, parte superior, e, quando visualizavam a aproximação das viaturas policiais, desciam um barranco e corriam para a comunidade "Portelinha". Diante disso, no dia dos fatos, foi com sua equipe da Força Tática para o local e lá se separaram, ficando um policial na Rua Honorato Faustino e outro na parte de baixo da Rua Ibitinga. Afirmou que, enquanto a equipe policial entrou pela Rua Ibitinga com a viatura policial, viram o acusado entregando algo ao condutor de veículo branco. Ao visualizarem a viatura, ele e o condutor do carro empreenderam fuga. O réu desceu correndo um barranco e jogando dinheiro no chão, momento em que se deparou com o policial Graziano e foi ele abordado. Revistaram-no e, em sua posse,

dentro de sua cueca, encontraram 128 porções de cocaína. Recolheram o dinheiro que ele dispensou durante a fuga, constatando que somava R\$ 48,00. Afirmou que, em entrevista informal, o acusado disse que estava realizando o tráfico para sustentar a família. Não conheciam o réu antes dos fatos.

No mesmo sentido as declarações do policial militar Graziano Ciola Dias, ouvido na delegacia de polícia (fls. 03) e nesta data (gravação).

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j.

11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo os 128 invólucros de cocaína, os quais eram destinados ao comércio e consumo de terceiros.

De fato, após os policiais tomarem conhecimento da forma de atuação dos traficantes no local dos fatos e da dinâmica de evasão, foram ao local e surpreenderam o acusado realizando a venda de entorpecentes ao condutor de um veículo, e, assim como era esperado, ele se evadiu do local ao ver a equipe tática, rumando em direção à comunidade, onde um dos policiais já o esperava. Ali ele foi abordado e, com ele, foram encontradas diversas porções de cocaína, além de dinheiro trocado que ele dispensou durante a fuga.

Tudo, pois, a indicar a traficância.

Outrossim, o próprio réu confessou a prática delitiva quando interrogado na fase policial, informalmente aos milicianos e hoje nesta audiência.

A quantidade de drogas que ele portava era incompatível com a situação de meros usuários.

Destarte, não há dúvida alguma de que ele as portava para fins de tráfico.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 106/107 e certidão de fls. 109).

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A quantidade de drogas, embora expressiva, não fugiu à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão da autoria do crime, mas deixo de diminuir as penas, uma vez que já fixadas no mínimo legal.

Inexistem agravantes. Também não há causas de aumento de pena.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas.

Assim, em razão do privilégio, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, possível aplicação do entendimento explanado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de "envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta

regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu KAUÃ LUÍS COSTA CESARIO a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA(M) RECORRER da sentença ora proferida.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do Ministério Público ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO para a acusação, nesta data. Regularize-se o sistema informatizado.

Por outro lado, recebo o recurso interposto pela Defesa.

Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

Regularize-se o sistema informatizado.

Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, ASSF, assistente judiciário, digitei.